

1500157-13.2022.8.26.0620

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO Não há qualquer elemento que evidencie a prática do tráfico ilícito de drogas. Em verdade, inexistiu flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga. Nesse compasso, considerando-se os depoimentos dos aludidos policiais militares, não há, nem de longe, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Vara Única

Avenida Coronel João Quintino, 137, Centro, Taquarituba - SP - cep 18740-000

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500157-13.2022.8.26.0620

Indiciado:

LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA

Data da Audiência:

18/08/2022

Réu Preso

Aos 18 de agosto de 2022, no formato misto, sob a presidência do(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, MM. Juiz(a) de Direito desta Comarca, comigo Escrevente a seu cargo adiante nomeado e ao final assinado, estavam presentes o(a) representante do Ministério Público, Dr(a). LUCAS MAESTER COLOMBO; o(a) réu LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, acompanhado(a) de seu(a) Defensor(a), Dr(a). Liliane Regina Rodrigues Balazina OAB 314834/SP; a(s) vítima(s) Saúde Pública; e a(s) testemunha(s) EMERSON DE OLIVEIRA GOMES, Ricardo Preinsack, Edison Domingues da Silva e Antonio Domingues. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi(ram) inquirida(s) a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, sendo a mídia disponibilizada posteriormente no sistema SAJ/PG, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pela MM(a). Juiz(a). Na sequência, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da testemunha Ricardo Preinsack, sendo, em seguida, homologada a desistência pelo(a) Magistrado(a). Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi encerrada a instrução probatória e determinada a realização dos debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: Meritíssimo Juiz, LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA foi denunciado e está sendo regularmente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, em virtude da prática dos fatos descritos na denúncia. O feito tramitou regularmente,

sendo que na presente data foram ouvidas testemunhas e interrogados os acusados. Entendo que o caso é de procedência da denúncia. A materialidade delitiva veio a ser confirmada pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, que demonstraram a natureza dos entorpecentes. Ademais, a prova produzida nos autos, demonstraram que na ocasião descrita na denúncia, o réu praticava o tráfico ilícito de entorpecentes. Policiais Militares que faziam patrulhamento pelo local (já conhecimento com sendo ponto de venda de drogas na cidade) avistaram o momento em que uma pessoa se aproximou de Luciano, em seguida ele foi até uma árvore, abaixou-se para pegar algo, que entregou a essa pessoa e recebeu algo em troca. Diante disso, os policiais decidiram por abordar o réu e com ele encontraram a quantia de R\$ 338,00 em moeda nacional (dividido entre os dois bolsos da frente da calça), bem como e 3 (três) porções de Cocaína. Em seguida, os policiais se dirigiram até a árvore onde haviam visto Luciano se dirigir, e lá lograram encontrar mais 10 (dez) porções de maconha e 23 porções de haxixe. Nesse mesmo local os policiais encontraram mais 393 (trezentos e noventa e três) eppendorf's vazios. Ouvidos na delegacia, os policiais militares Emerson de Oliveira Gomes e Ricardo Preinsack relataram que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas quando localizaram o réu em atitude suspeita. Ato contínuo, após conversar com uma pessoa, o réu se dirigiu até uma árvore, pegou um objeto e entregou ao indivíduo. Nesse momento, realizaram a abordagem do acusado, sendo localizadas a quantia de R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais) e três porções de cocaína. Além disso, foram localizadas 10 porções de maconha, 23 porções de haxixe e 393 pinos de "eppendorf" na árvore em que o réu foi avistado (fls. 03/04). Em juízo, a testemunha Emerson prestou o depoimento no mesmo sentido, corroborando a narrativa de seu colega na etapa inquisitorial. Em juízo, a testemunha de defesa Edison Domingues da Silva nada trouxe de relevante, pois não presenciou o fato. Em juízo, a testemunha de defesa Antônio Domingues também não estava no momento da abordagem e, assim, nada trouxe de relevante. Ouvido na polícia, o réu Luciano Silva de Oliveira permaneceu em silêncio (fls. 05). Em juízo, negou o delito. Disse que as drogas apreendidas não eram do declarante. A quantidade e divisão do entorpecente, a forma como estavam acondicionadas, o local e as circunstâncias da prisão e as informações anteriores obtidas pelos policiais demonstram o dolo da traficância. Ante o exposto, aguardo seja a presente ação penal julgada PROCEDENTE, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, em obediência ao disposto no art. 42 da Lei de Drogas, observo que a pena-base deverá ser afastada do patamar mínimo legal em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 138/144). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Pelos mesmos motivos, inviável a aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, devendo o regime inicial de cumprimento de pena ser o fechado, inviabilizando a aplicação de quaisquer benefícios. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) réu foi dito: Meritíssima Juíza Nobre Representante do Ministério Público Trata-se de Ação Penal, onde o acusado foi denunciado por incurso no delito contido no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo em vista que no dia 07 de abril de 2022, às 22h00, o mesmo supostamente trazia consigo para fins de venda ou entrega a qualquer título ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) porções de haxixe, com peso de 12,4g; 10 (dez) porções de maconha, com peso de 16,2g; e 3 (três) porções de cocaína, com peso de 0,1g. Ocorre que os fatos narrados acima não possuem tal veracidade para o acusado ser tipificado penalmente no artigo 33 da Lei 11.343/06, pois como consta na denúncia de fls. 69/72, que o acusado estaria comercializando os entorpecentes apreendidos, fato o qual não foi comprovado pela denúncia, tampouco pelos policiais envolvidos no caso, conforme consta a seguir: "Policiais Militares que faziam patrulhamento pelo local (já conhecimento com sendo ponto de venda de drogas na cidade) avistaram o momento em que uma pessoa se aproximou de LUCIANO, em seguida ele foi até uma árvore, abaixou-se para pegar algo, que entregou a essa pessoa e recebeu algo em troca. Diante disso, os policiais decidiram por abordar o denunciado e com ele encontraram a quantia de R\$ 338,00 em moeda nacional (dividido entre os dois bolsos da frente da calça), bem como e 3 (três) porções de COCAÍNA. Em seguida, os policiais se dirigiram até a árvore onde

havia visto LUCIANO se dirigir, e lá lograram encontrar mais 10 (dez) porções de MACONHA e 23 porções de HAXIXE. Nesse mesmo local os policiais encontraram mais 393 (trezentos e noventa e três) eppendorf's vazios." Excelência, conforme própria alegação dos policiais "avistaram o momento em que uma pessoa se aproximou de LUCIANO, em seguida ele foi até uma árvore, abaixou-se para pegar algo, que entregou a essa pessoa e recebeu algo em troca.". Justamente não houve por parte do denunciado qualquer prática ilegal de tráfico, mas sim, ante a sua dependência química, a compra das 3 (três) porções de cocaína., que inclusive foi adquirido em outro local. No que tange ao valor de R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais) em moeda nacional encontrado nos bolsos da frente da calça, refere-se ao pagamento pelo seu trabalho de servente de pedreiro, conforme corroborado nos autos através de declaração feito a punho do próprio empregador Edson Domingues da Silva. Diante de tais depoimentos efetuados pelos próprios policiais, observamos Excelência, a improcedência de tal acusação, visto que em momento algum os policiais de fato avistaram ou presenciaram a comercialização das drogas apreendidas, como podemos observar. No mais, após o termino da instrução criminal temos que o acusado nega que tivesse em seu poder os entorpecentes, e os policiais afirmam que o viu o momento em que uma pessoa se aproximou de LUCIANO, em seguida ele foi até uma árvore, abaixou-se para pegar algo, que entregou a essa pessoa e recebeu algo em troca, mas não conseguem dizer se não é essa pessoa quem é de fato o traficante, já que não houve a abordagem desse segundo indivíduo. É certo, ainda, que não se comprovou se qualquer dúvida que o acusado estivesse efetivamente na posse dos entorpecentes e que este se destinava ao comercio ilícito. Alias, sequer aconteceu!!! Deve, por tanto, militar em favor do réu o princípio "in dubio pro reo". Outrossim, foram juntados outros documentos que comprovam que o denunciado não é traficante de drogas e sim mero usuário, desde os seus 14/15 anos, inclusive já esteve internado no ano de 2020 e claro e notório que necessita de internação compulsória para retomada ao tratamento. (CID F 10 - F19). Outrossim, em que pese a infelicidade do seu vício, o acusado é um excelente filho, possui doutrina familiar, é amado pelos seus familiares, e ainda, trabalha com dedicação e afinco. Neste prisma, a qualificação da tipificação penal, seria para o crime de uso próprio, o qual encontra-se positivado no artigo 28 da Lei nº 11.343/06: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal (grifo nosso), drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas. Por fim, frisa-se que não há nos autos elementos suficientes para a procedência da presente ação e via de consequência a condenação do Acusado. NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO Não há qualquer elemento que evidencie a prática do tráfico ilícito

de drogas. Em verdade, inexistiu flagrante de venda, detenção de usuários, apreensão de objetos destinados à preparação, embalagem e pesagem da droga. Nesse compasso, considerando-se os depoimentos dos aludidos policiais militares, não há, nem de longe, qualquer importe fático que conduza à figura do tráfico de drogas ilícitas, ao contrário do que aduz o Parquet. Nada obstante, tal circunstância, isoladamente, não tem o condão de justificar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, mormente do que dispõe o artigo 28, §2º, da Lei nº. 11.343/06, verbis: Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (. . .) § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Nesse diapasão, os elementos de convicção, de que dispõe o caderno processual, mostram-se frágeis a atestar a prática da traficância. Dessa forma, conduz-se para a hipótese de que o Acusado se enquadra na figura do usuário de droga, na estreita ordem delimitada no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006. DO EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E A ISENÇÃO DE PENA Colhe-se do depoimento prestado pelo Acusado aos policiais militares que o mesmo se declarou viciado em drogas como a maconha, crack, cocaína, álcool. Tais substâncias inegavelmente diminuem a capacidade de se

entender o caráter ilícito da conduta delituosa. E foi o caso do Acusado, o qual há anos é dependente químico destas drogas. Por conta disso, já não mais reponde à sua capacidade intelectual e volitiva de obstar a utilização da droga. Resultou que essa incapacidade de dominar seus impulsos, fizesse-o cometer o delito de usar a droga (artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006), para, assim, satisfazer o impeto desenfreado de saciar esse impulso. O Acusado não foi capaz de, à época dos fatos, minimamente compreender a ilicitude do consumo dessa droga, estava totalmente dominado e seu campo cognitivo se encontrava devastado pela nefasta droga. Não se questiona, aqui, se o Acusado é ou não dependente. Em verdade, o que se busca com referida prova é: DEMONSTRAR QUE O MESMO ERA INIMPUTÁVEL, VISTO QUE ERA INCAPAZ DE VERIFICAR LUCIDAMENTE A ILICITUDE DO DELITO PERPETRADO, sendo que neste sentido temos o artigo 45 da Lei nº. 11.343/2006, a seguir: Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo, por força pericial, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. Contata-se do artigo supramencionado que trata de uma das causas de exclusão da culpabilidade, a inimputabilidade que traz o artigo 45 deverá ser constatada por meio de prova pericial, ou seja, exame toxicológico do Acusado. Destarte, para que tal pleito não seja prejudicado pela preclusão, de logo o Acusado formula pedido de produção de provas, qual seja: o exame de dependência toxicológica, a fim de se obter a isenção de pena por dependência química. DA INSUFICIÊNCIA MATERIAL DELITIVA Não se pode negar a inocência do acusado, ante a ausência de provas robustas que possam imputar ao mesmo o suposto delito. Assim, caso a presente ação penal seja julgada procedente, haverá um dano irreparável ao Acusado. Deve-se atentar ao fato de que condenar com o perigo abstrato é condenar sob a égide da incerteza da lesão ou do potencial de lesão na conduta do cidadão enquanto a conduta do julgador é revestida de precisão quanto à sua efetiva lesão à Dignidade, fundamento da República. A Dignidade deve ser protegida de forma eficaz e há um conflito, ainda não superado, com os delitos de perigo presumido, pois são carentes de ofensividade. Não pode restar qualquer dúvida no sentido de que o bem jurídico tem estrita relação com a materialidade constitucional, representado pelos preceitos e princípios que encerram a noção de Estado Democrático e Social de Direito. Não há dúvida, pois, que as baterias do direito penal do Estado Democrático de Direito devem ser direcionadas para o combate dos crimes que impedem a concretização dos direitos fundamentais nas suas diversas dimensões. DA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO Excelência, temos como basilar o princípio da presunção de inocência e do “in dubio pro reo”, os quais encontram guarida no artigo 5º da Constituição Federal, sendo cláusula pétrea, o que demonstra sua superioridade e relevância para o Estado Democrático de Direito, devendo servir de baliza permanente na aplicação da Lei. Assim sendo, para a efetiva condenação do Acusado a prova deve ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio do “in dubio pro reo”. A aplicação do princípio do “in dubio pro reo” implica que na dúvida interpreta-se em favor do Acusado, tendo em vista que a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. A regra contida no artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, traz em seu bojo que a Lei Penal adota implicitamente este princípio. Portanto, temos uníssono que não conseguindo o Estado angariar provas suficientes da materialidade e autoria do crime, o juiz deverá absolver o Acusado, aplicando-se, assim, o princípio do in dubio pro reo. Conclui-se que a absolvição do Acusado nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal é medida justa, visto não existirem provas suficientes e robustas para a condenação do acusado, bem como não existem provas de ter o acusado concorrido para a prática da infração penal. DA CONCLUSÃO E PEDIDOS Ex Positis, perante tudo que foi abordado, somado aos princípios garantidos em nossa Carta Magna, ainda relevando a conduta do acusado e os elementos subjetivos do caso, Requer desde já a absolvição ainda é

medida que se impõe nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal é medida justa, visto não existirem provas suficientes e robustas para a condenação do acusado, bem como não existem provas de ter o acusado concorrido para a prática da infração penal, aplicado o princípio do "in dubio pro reo". Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a desclassificação do tráfico para uso, conforme artigo 28, §2º, da Lei nº. 11.343/06, bem como para a realização do exame toxicológico a fim de obter o benefício do artigo 45, da Lei nº. 11.343/06. Termos em que, Pede deferimento. Na sequência, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Trata-se de ação penal em que LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, do Código Penal. Segundo consta na exordial, no dia 07/04/2022, às 22h00, na Rua André Garcia Domingues, nº 70, Centro, Taquarituba/SP, LUCIANO vendeu, tinha consigo, bem como em depósito, (i) 23 (vinte e três) porções de HAXIXE, com peso de 12,4g; (ii) 10 (dez) porções de MACONHA, com peso de 16,2g; e (iii) 3 (três) porções de COCAÍNA, com peso de 0,1g, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fls. 11/12), Laudo de Constatação Preliminar (fls. 17; 18; E 19), Fotos (fls. 25/31) e Laudo Toxicológico Definitivo (a ser juntado), tudo em sem autorização e em desacordo com determinação legal. A prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva (fls. 73/75). O réu foi notificado (fl. 120) e apresentou defesa prévia (fls. 90/91). Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, sendo o réu interrogado ao final. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em sede de alegações finais. Pugnou o Ministério Público pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou benefícios no tocante a pena. É o Relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. Passo a análise do mérito. A materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12); pelos autos de constatação (fl. 17/19); pelo boletim de ocorrência (fls. 06/09); pelas fotografias (fls. 25/31); pelos laudos periciais (fls. 109/111, 112/114 e 115/117); bem como pela prova oral colhida. A autoria do crime de tráfico também está devidamente demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, a indicar que o denunciado realmente vendia, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de traficância, os entorpecentes apreendidos nestes autos, de maneira que não há que se falar em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa. A testemunha EMERSON DE OLIVEIRA GOMES, Policial Militar, em sede policial (fl. 03), disse que "estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o indiciado parado em um local que é conhecido como ponto de venda de drogas, permaneceram observando a movimentação por alguns minutos, quando avistaram uma pessoa se aproximar do autor e ele ir até o pé de uma árvore, pegar um objeto, entregar para essa pessoa e receber

algo em troca. Suspeitando se tratar de venda de drogas, um de seus companheiros desceu da viatura e foi em direção ao indiciado enquanto o declarante e o motorista da viatura deram a volta e uma praça e o abordaram pelo outro lado. Foi realizada revista pessoal no indiciado e nos bolsos de sua calça jeans foram localizados a quantia de R\$ 338,00 (trezentos e trinta e oito reais) dividido nos dois bolsos da frente, bem como as três porções de substância aparentando ser cocaína. Aos pés da árvore em que o indiciado foi avistado pegando um objeto foram localizadas as 10 porções de substância aparentando ser maconha, 23 porções de substância aparentando ser haxixe e 393 pinos de "eppendorf". O indiciado foi indagado acerca da propriedade da droga e da origem do dinheiro, sendo que respondeu ser usuário e que o dinheiro era um pagamento pelo seu trabalho de servente de pedreiro. Tendo em vista a situação que observaram, bem como a permanência do indiciado em local próximo ao que estava as drogas foi dada voz de prisão ao indiciado e conduzido para esta unidade policial". Em juízo, corroborou a versão inicial. Afirmou, ainda

que foram até a casa do réu e a mãe dele disse que ele realmente era dependente químico, mas que não trabalhava na época. Não tinham outras pessoas com o réu, tinham apenas um casal jogando linha e anzol no lago e eles foram abordados e nada foi encontrado. As testemunhas de defesa EDISON DOMINGUES DA SILVA e ANTONIO DOMINGUES foram abonatórias da conduta do réu. O réu LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, em sede policial (fl. 05), preferiu manter-se em silêncio a respeito dos fatos. Em juízo, disse que estava com um casal, mas que somente ele foi abordado. Que tinha pouca droga para uso pessoal. Que a droga achada no mato não era dele. Foi pressionado pelo policial a assumir o porte das drogas ou indicar de quem elas eram. Que o policial também ameaçou incriminar sua mãe. Que os policiais conversaram com o casal, mas que eles foram liberados. Assim, considerando os firmes e seguros relatos prestados pelos policiais, em juízo e quando ouvidos em solo policial, tem-se que merecem eles acolhimento, ainda mais ao se considerar que corroboram o conjunto probatório coligido aos autos, não tendo, outrossim, restado comprovado no feito motivo válido e concreto para se suspeitar da parcialidade dos agentes públicos. Como se sabe, é através do trabalho da polícia que se consegue a apuração dos delitos. São os policiais, no exercício da repressão ao crime, que conseguem desvendá-los. Assim, ressaltada hipótese de restar comprovada animosidade contra o réu, ou verdadeiro interesse na prolação do desate condenatório, seus depoimentos não merecem ser desqualificados, sendo esta a hipótese dos autos, não se mostrando crível que policiais fossem escolher pessoa inocente para injusta e criminosamente imputar a prática delitiva. Nesse sentido, merece destaque: "Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275) e "APELAÇÃO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE VARIEDADE E QUANTIDADE DE DROGAS INDIVIDUALIZADAS EM PORÇÕES - TRAFICÂNCIA CARACTERIZADA INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA DUVIDAR DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A RESPONSABILIDADE PENAL DO APELANTE: Flagrado o agente na posse de diversos entorpecentes prontos para o comércio, encontrando-se, em circunstâncias que evidenciam a traficância, aliadas à palavra dos policiais que não teriam motivo algum para uma falsa imputação, impossível cogitar a absolvição" (TJSP Apelação Criminal com Revisão nº 0000344-79.2008.8.26.0590 Des. Rel. Willian Campos 4ª Câmara de Direito Criminal j. 29/11/2011). Quanto à adequação típica, a conduta do réu mostra-se compatível com o tráfico de drogas, especialmente o verbo típico "trazer consigo" para fins de traficância, nos termos do art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06. Como cediço, trata-se de tipo penal múltiplo de conteúdo variado, com dezoito verbos nucleares que o caracterizam, motivo por que basta a execução de uma das condutas típicas para a caracterização do crime. Ademais, seria desnecessária, para a incidência do tipo penal em tela, a ocorrência de ato de mercancia, bastando, para tanto, que a conduta do agente se amolde a qualquer um dos verbos nucleares, o que ocorreu na situação em tela, conforme teor das mensagens contidas no celular apreendido. No presente caso, o depoimento dos policiais que atuaram na diligência que redundou na apreensão da droga, aliados às demais circunstâncias existentes nos autos, sinalizam que o entorpecente apreendido estava destinado à traficância, já que, a contrario sensu, conforme previsão do art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/06, para identificação do usuário é necessário atentar "à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". Colhe-se dos autos que: a) policiais avistaram o acusado, em atitude suspeita, em ponto de tráfico de drogas; b) os policiais presenciaram o momento em que uma pessoa se aproximou do acusado, quando então ele foi até uma árvore, pegou algo, entregou para essa pessoa e recebeu algo em troca; c) foram apreendidas três porções de cocaína com o acusado; d) bem como a quantia de R\$ 338,00 em dinheiro; e) apreenderam, junto a árvore onde viram Luciano pegar alguma coisa, mais 10 porções de maconha. 23 porções de haxixe e 393 eppendorf's vazios. Por tais fundamentos, ausente causa de exclusão da ilicitude e da culpabilidade, impõe-se a condenação do réu pela prática do delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33,

caput, da Lei n.º 11.343/06. Por fim, aponto que não se mostra viável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, notadamente diante da reincidência do acusado, bem como da quantidade de entorpecente apreendida, de imenso potencial lesivo, de modo que a aplicação da minorante legal serviria de estímulo à manutenção do comportamento criminoso, restando evidente que o acusado estava inserido em esquema criminoso sofisticado, tratando-se de mais uma engrenagem a fomentar o narcotráfico, não podendo a conduta ser considerada como de menor envergadura. Lembro que quis o legislador favorecer o autor eventual de tráfico de "pequena" monta, para hipóteses extremamente excepcionais e especiais, em que todas as circunstâncias sejam absolutamente favoráveis ao autor do delito, o que não é o caso dos autos, conforme já exposto. Admitir a minorante, neste caso, apenas adensaria e justificaria a perpetuação da narcotraficância nesta região de fronteiras, já tão afetada pela posição territorial que ocupa. Passo a dosimetria. Na primeira fase do cálculo, em atenção às circunstâncias do caso em tela e ao que dispõe o artigo 42, da Lei Antidrogas e o artigo 59, do Código Penal, verifico que a natureza e variedade de droga encontrada (23 porções de haxixe, com peso de 12,4g; 10 porções de maconha, com peso de 16,2g; e 3 porções de cocaína, com peso de 0,1g) merece maior desvalor, visto denotar que grande número de indivíduos seriam afetados por seu poder viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Na segunda fase do cálculo, o réu possui a agravante da reincidência, eis que o réu, quando do cometimento do delito em tela, já ostentava condenação anterior definitiva pela prática de roubo (autos nº 0013919-18.2014 - fls. 51 e 56), nos termos do artigo 63, do Código Penal. Assim, a pena deve ser agravada e fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Por fim, na terceira fase do cálculo, conforme alhures fundamentado, deixo de aplicar o redutor previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não existindo causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as penas acima cominadas. Fixo o regime FECHADO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal). Fixo, ainda, o dia-multa no mínimo legal mínimo, diante da falta de informações sobre a condição econômica do réu. Ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, não é viável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e suspensão condicional da penal. A prisão preventiva outrora determinada deve ser mantida uma vez que seus motivos permanecem hígidos, não havendo elementos que possam alterar a conclusão de necessidade de prisão para salvaguarda da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado LUCIANO SILVA DE OLIVEIRA, por ter praticado fato tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, com regime inicial FECHADO, além de pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa. Condono o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a)

no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Determino a perda dos bens apreendidos utilizados para o comércio ilícito de drogas. Após o trânsito em julgado: (a) Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes

autos, na forma do art. 72 da Lei n. 11343/06; (b) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (c) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (d) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (e) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (f) Ofícios de praxe. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se. Nada mais. Do que para constar lavrei o presente termo que lido e achado conforme vai assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, digitei.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.